

1501333-82.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso). A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE TELEAUDIÊNCIA

Processo nº:

1501333-82.2022.8.26.0537, C - 2022/000829

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170565/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 25729474 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2170565 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DE FARIAS

Em 18 de outubro de 2022, caracterizada a 'gravíssima questão de ordem pública' prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal, realiza-se o presente ato processual por videoconferência com a prévia concordância das partes, por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito. Pela MMA. Juíza foi dito que: "A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19) e declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) persiste, malgrado a regressão parcial no Estado de São Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social pelo Poder Executivo. Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção das medidas aptas a preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, colaboradores e jurisdicionados nesse período de transição, o CNJ autorizou a realização de audiências telepresenciais, sendo que no caso concreto não foi ofertada recusa ou resistência pelas partes. A audiência será realizada com a transmissão de sons e imagens em tempo real, sempre que possível, permitindo-se a interação entre a Magistrada, as partes e demais participantes.". Cumpridas as formalidades legais, apresentaram-se o representante do Ministério Público, Dr. Rogerio Augusto de Almeida Leite e o réu: GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DE FARIAS, Brasileiro, Solteiro, Cabeleireiro, RG 54843406, CPF 497.726.568-84, pai FERNANDO PEREIRA DE FARIAS, mãe MARIA IRAIDES DA SILVA BARBOSA, Nascido/Nascida 09/08/1999, de cor Branco, natural de São Bernardo do Campo - SP, Outros Dados: gustavobarbosadefarias@gmail.com, com endereço à Rua Anna Molon Lazzuri, 199, Fone: (11) 96562-1008 ou 41092051, dos Casa, CEP 09840-080, São Bernardo do Campo - SP,

assistido por seu Advogado, Dr. Francisco Isaias da Costa, OAB/SP 404078. PRESENTES, ainda, as testemunhas de acusação: 1) FÁBIO ROBERTO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 33231059, CPF 226.175.738-77, nascido em 07/07/1982, Avenida Joao Firmino, 425, 3º DP SBCampo, Assuncao - CEP 09810-250, São Bernardo do Campo-SP; e 2) LINEU CARLOS CUNHA MATTOS FILHO, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 29073313, CPF 298.707.508-18, pai Lineu Carlos Cunha Mattos, mãe Helena dos Santos Cunha Mattos, nascido em 18/12/1981, Avenida Joao Firmino, 425, 3º DP SBC, Assuncao - CEP 09810-250, São Bernardo do Campo-SP; e a testemunha de defesa: ISRAEL RIBEIRO GONÇALVES, Brasileiro, RG 557571996, pai: José do Carmo Gonçalves, mãe: Maria do Socorro Ribeiro, endereço: Travessa Novo Horizonte, 13, dos Casa, SBC. AUSENTE a testemunha de defesa: ADEILDO ALVES OLIVEIRA. Fica consignado que, antes de dar início à audiência, ao(s) acusado(s) foi garantida a entrevista prévia, sigilosa e reservada com o seu defensor em tempo adequado à preparação de sua defesa, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. Réu(s) e defensor foram informados de que, ao cabo da oitiva das testemunhas, seria garantida nova conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas. O(A) MM(a). Juiz(a) informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams" e, a seguir, as testemunhas foram cientificadas a apresentar seus documentos de identificação para serem devidamente qualificadas e a manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Defesa, por ela foi requerido prazo de 05 dias para a regularização da representação processual, com a juntada do substabelecimento, e os benefícios da Justiça Gratuita vez que o acusado não possui condições financeiras para eventualmente arcar com as custas processuais. Pela MMA. Juíza foi dito: "Defiro o prazo de 05 dias requerido pela Defesa para a regularização da representação processual. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao réu. ANOTE-SE E TARJE-SE O PROCESSO COM A COR INDICATIVA.". Após, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou a abertura do presente termo para que ficasse constando que os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates da causa seriam todos colhidos pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. A seguir, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Fabio, Lineu e Israel. Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha Adeildo, o que foi homologado pelo(a) MM(a). Juiz(a). A seguir, garantiu-se ao Réu e defensor conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas, tendo a Defesa informado a desnecessidade. A seguir, o réu foi interrogado. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi dito que declarava encerrada a fase de instrução criminal e passou-se à fase do artigo 402 do CPP, sendo que pelas partes nada mais foi requerido. Após, foi dada oportunidade dos debates orais às partes. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida e lida a r. sentença que segue: Vistos. GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DE FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2022, por volta das 16h40min, na Rua Reginalda Campodônio Dias, altura do nº 75, bairro Assunção, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, vendia e tinha em depósito, para fins de traficância, drogas consistentes em 110,4g (massa líquida) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), também conhecida como maconha, acondicionados em 47 invólucros plásticos; 14g (massa líquida) de cocaína, acondicionados em 46 invólucros plásticos; e 4,5g (massa líquida) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 45 invólucros plásticos; substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), produto da mercancia ilícita, consoante auto de exibição e apreensão de págs. 14/15, laudo de constatação provisória de págs. 18/20 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 141/143. Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado, previamente ajustado, agindo com identidade de propósitos e unidade de designios com o adolescente Brian Galvão Martins, vendia e tinha em depósito diversas embalagens individuais de drogas, para fins de comercialização. Policiais civis, sabendo de local em que ocorre intenso tráfico de drogas, dirigiram-se ao endereço acima, em viatura descaracterizada. Então, os policiais notaram que vários indivíduos se

dirigiam até o local e estabeleciam contato com o acusado, que trajava uma camiseta vermelha. A seguir, ele se dirigia ao adolescente Brian Galvão Martins, retirava o que parecia ser uma porção de droga e entregava ao suposto comprador. Após observarem essa dinâmica se repetir por algumas vezes, os policiais decidiram realizar a abordagem. Neste momento, o adolescente abandonou uma sacola e empreendeu fuga, deixando cair seu aparelho celular, enquanto o acusado foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com GUSTAVO, apenas o valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais). Indagado, o acusado afirmou estar traficando drogas, especificando que a dinâmica era aquela observada, ou seja, os usuários se aproximavam dele, falavam o que queriam comprar, entregando a ele o dinheiro. Ele, por sua vez, ia ao encontro do adolescente, e retirava a porção de droga, entregando ao usuário. Os policiais, então, se dirigiram até a posição em que o infante estava e apreenderam uma sacola, na qual havia porções semelhantes a maconha, cocaína e crack, além do aparelho celular que ele havia deixado cair. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia e confessou a prática delitiva. Disse, ainda, que o gerente responsável pelo ponto de venda de substâncias entorpecentes é Lucas Volcov de Araújo, que foi por ele reconhecido fotograficamente (págs. 09 e 27). Então, após autorização judicial, a D. Autoridade Policial e seus agentes procederam à devassa no aparelho telefônico do adolescente e confirmaram sua identidade, tratando-se de Brian Galvão Martins, conforme relatório de investigação de págs. 73/74. A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de valor em espécie, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de drogas. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs. 04/77. O réu ofertou defesa preliminar (pág.154/162) Recebida a denúncia às págs. 176/180, o réu foi citado (pág.203). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa, interrogando-se o réu. Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, com reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, fixando-se regime aberto para início de cumprimento de pena. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO. A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria. Presente, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão de págs. 14/15 (dinheiro, aparelho celular e droga), nos laudos de constatação às págs.18/20, químico-toxicológico às págs.141/143 e pericial às págs. 132/133 (aparelho celular), bem como no comprovante de depósito de pag. 65. Quanto à autoria, na primeira fase da persecução penal o acusado confessou a prática do delito: “que está ciente de seus direitos constitucionais; que confessa que estava traficando drogas; que enfrente problemas financeiros

e hoje seria o primeiro dia fazendo tal ato; que estava acompanhado por um indivíduo que conheceu no local; que sabe dizer que ele se chama Bryan; que não sabe onde o mesmo reside ou qualquer outro dado qualificativo dele; que era responsável por atender diretamente os usuários e ir até Bryan pegar a porção de droga; que foi abordado por policiais civis; que Bryan correu; que estava na posse do dinheiro quando da abordagem; que Bryan deixou a sacola no chão e correu. o interrogado confessa a pratica do crime de tráfico de drogas....” (pág. 09). Em Juízo, retratou-se. Disse que estava no local apenas na condição de usuário. O adolescente Bryan era o traficante e correu com a chegada dos policiais civis, dispensando a sacola contendo droga, deixando cair o aparelho celular dele. A retratação da confissão policial não produz efeitos por si mesma. Cumpre ser acompanhada de provas elidentes, o que não se vê patenteado na espécie. Nessa linha: “É necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na Delegacia ou em Juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências”(Rel. CORRÊA DE MORAES – RJTACRIM 43/144). “De regra, a prova constante no inquérito policial não deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito ocorre sob clandestinidade. As confissões nele

obtidas regularmente e estando os seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos têm alto valor probante, devendo ser aceitas, se não elididas na fase judicial" (Rel. GONÇALVES SOBRINHO - JUTACRIM 32/265). Ademais, a negativa de autoria ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução. Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Fábio Roberto de Oliveira e Lineu Carlos Cunha Mattos Filho, em relato coeso e harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência que realizaram na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida quanto à autoria: Dirigiram-se ao local do fato, conhecido ponto de tráfico de droga, intenso, da região, em viatura descaracterizada. Efetuaram breve campana e ali visualizaram o acusado em atitude típica da mercancia ilícita. Indivíduos se dirigiam até o local e estabeleciam contato com o acusado. GUSTAVO, por sua vez, dirigia-se até o adolescente que estava em poder da sacola contendo a droga, retirava o que parecia ser uma porção de droga e a entregava ao usuário. O fato repetiu-se por mais de uma vez. Quando se aproximaram para efetuar a abordagem, o adolescente 'Bryan' fugiu correndo, deixando cair o aparelho celular dele, e dispensando a sacola contendo porções individuais de cocaína, maconha e crack. O réu, sem tempo de reação, foi abordado no local. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de pouco menos de cem reais, em dinheiro trocado. Inquirido, o réu confessou a prática do delito e o envolvimento do adolescente 'Bryan' no tráfico de droga, adolescente que havia logrado fuga. Autorizado judicialmente a devassa em tal aparelho celular, pelo contato 'pai' da agendas, conseguir qualificar o menor de idade, confirmando que se tratava de Brian Galvão Martins. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846). Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287). Neste sentido: "Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes." (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª T., DJe 26/10/2018). Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime. Nesta linha: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câ. Crim., julgado em 27/01/2015). Destaca-se, quanto ao envolvimento do menor de idade Brian no delito em apreço, apto a configurar a causa de aumento de pena indicada na exordial, não apenas a apreensão de seu aparelho celular no local do fato, a autorização judicial de devassa que permitiu a sua identificação cabal, mas principalmente a oitiva de seu genitor. Com efeito, a pág.145, DOUGLAS JOSÉ GONÇALVES MARTINS declarou que: "...possui da Guarda Provisória de Brian, com relação aos fatos esclarece que seu filho é usuário de drogas Múltiplas e que o mesmo também trafica drogas no B. do Carminha . Indagado ao declarante sobre dos fatos ocorrido no dia 23/06/2022 , informa o declarante qu seu filho disse que estava na companhia com um amigo fazendo entrega de Ifood numa Moto , e que quando foi buscar droga "loja na comunidade do Vila Carminha , correu dos Polciais Civis e quebrou o pé. Informa o declarante que Brian confirmou ao declarante que estava traficando na companhia de "salsicha" tratando-se de Gustavo no dia do ocorrido e

que quando correu dos Policias largou a drogas e celular que pertence a Brian pelo caminho, tendo "salsicha sido preso" - grifo nosso. O apelido do acusado - 'salsicha' - citado nas declarações do pai do adolescente, foi confirmado pelo réu e por sua testemunha de defesa em Juízo. Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial. Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (47 invólucros plásticos de maconha, 46 invólucros plásticos de cocaína e 45 invólucros plásticos de crack), a forma como acondicionada (individualmente), o local da prisão (conhecido ponto da mercancia ilícita), a apreensão de dinheiro trocado e as circunstâncias da prisão, tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiro. Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Nesse ponto, cumpre anotar, outrossim, que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga a usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia. Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu. Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido. Finalmente, não se olvida a declaração do acusado de que é usuário de droga. Ainda que fosse adotada como verdadeira (não existe prova de que o agente estava sob efeito de tais substâncias durante a ação criminosa), a premissa não teria o condão de afastar a culpabilidade do réu. Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo apto a revelar comprometimento da capacidade cognitiva em razão do uso de entorpecentes. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura, negando a prática do delito. Não há, ademais, relato de alteração comportamental ou de saúde. Conforme preceitua o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007). Ainda nessa quadra, saliente-se que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante. É sabido que, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768). Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Não há agravantes e atenuantes a considerar. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado praticava a mercancia ilícita com adolescente, a pena é elevada em 1/6,

alcançando o montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O réu preenche todos os predicados legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa. Todavia, há óbice à aplicação do índice redutor máximo. Com efeito, não é possível olvidar a razoável quantidade de droga – de natureza diversa – apreendida – 138 porções (47 invólucros plásticos de maconha, 46 invólucros plásticos de cocaína e 45 invólucros plásticos de crack). O benefício de redução de pena previsto no mencionado §4º não foi instituído pelo legislador para atuar como redutor máximo automático das sanções correspondentes ao tráfico de droga no grau máximo. Teve o escopo de disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento de individualizar as reprimendas correspondentes a esse delito. A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador. O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do inculpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato. Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou “qualidade”) e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma). O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”. Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena de metade (1/2), o que perfaz 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado. A jurisprudência majoritária acolhe o entendimento de que tais circunstâncias devem ser apuradas nesta etapa da dosimetria da pena, método compatível com a melhor hermenêutica e mais próximo da correta interpretação e aplicação do Direito como ciência (Apelação Criminal nº 0003571-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 11/05/2010; Apelação Criminal nº 0074313-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/08/2011; Apelação Criminal nº 0011319-96.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/10/2012). Ainda nessa linha: AgRg no HC 209930/ES, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgado em 18/10/2012; HC 244726/ES, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/10/2012. O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração. O regime para o início de cumprimento de pena é o aberto. Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo). Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014). Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado. Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência. Essa decisão foi

acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016. Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado. Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza hedionda. Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”) trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (grifo nosso). A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º (“tráfico privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”. Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”. A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber: A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único. No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte. Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal. Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto. Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. A pena base foi fixada no mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Cumpre-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP. De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do “sursis”, não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à

reiteração da conduta. Na espécie, o réu portava quantidade razoável de droga. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal. A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador. O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DE FARIAS, qualificado nos autos à pág. 164, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado. O réu respondeu ao processo solto. Poderá apelar em liberdade, não alterada a situação fática e considerado a pena e regime aplicados. Decreto o perdimento do dinheiro, oriundo do tráfico de droga, e o aparelho celular apreendido nos autos, certamente usado na mercancia ilícita. De imediato, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência admonitória; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República; c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário; d) Efetue-se a transferência do dinheiro apreendido nos termos das NSCGJSP, efetuando-se as comunicações necessárias; e) oficie-se à Autoridade Policial noticiando que o aparelho celular está disponível para destruição. Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada em audiência, a sentença foi explicada ao acusado. Todos os presentes foram devidamente intimados e cientificados da sentença. Pelo acusado e seu defensor, bem como pelo Promotor de Justiça foi dito que NÃO DESEJAVAM RECORRER DA R. SENTENÇA. Em seguida, determinou que fosse registrada e cumprida a sentença nos seus termos, certificando-se o trânsito em julgado para as partes. Além disso pela MMA. Juíza foi dito: "Designo audiência admonitória para o dia 23 de novembro de 2022, às 16h00, que se realizará PRESENCIALMENTE no Cartório da Quinta Vara Criminal de São Bernardo do Campo (endereço no cabeçalho - R. Vinte e Três de Maio, 107 - Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP, 09606-000 - TELEFONE DO CARTÓRIO: (11) 2845-9613 ou (11) 95251-1592). O réu saiu intimado, neste ato, da data acima. Oportunamente, arquivem-se os autos.". O presente termo foi assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As partes concordaram com o exposto na presente ata. O(s) depoimento(s), o(s) interrogatório(s) e os debates da causa foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais, com as formalidades legais, encerrou-se o presente termo. Eu, _____ (MSD), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Promotor(a):

Defensor(a)/Advogado(a): Réu(s):